

1500353-12.2021.8.26.0266

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL VIEIRA PATARA

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... delito por idêntico crime de tráfico de drogas nestes autos, no dia 03.03.2021, sendo posto em liberdade; ele voltou a ser preso em flagrante por novo tráfico de drogas, conforme se constata por simples pesquisa no E-saj, em análise do feito nº 1518636-83.2021.8.26.0266, o que demonstra concretamente que ele se dedica à atividade criminosa, apresentando conduta criminosa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

3ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, ., Centro - CEP 11740-000, Fone: (13) 3422-1215,

Itanhaém-SP - E-mail: itanhaem3@tjsp.jus.br

Processo nº:

1500353-12.2021.8.26.0266

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Repte(a)(s):

Justiça Pública

Reqdo(a)(s):

DENIS GONÇALVES VIANA e GUILHERME SILVA RAHAL

MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). RAFAEL VIEIRA PATARA.

Vistos.

DENIS GONÇALVES VIANA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, porque no dia 03.03.2021, por volta das 18h30min, na Rua Quarenta, nº 85, Gaivota, nesta cidade e comarca de Itanhaém, o agente supra apontado, agindo previamente ajustado e com identidade de propósitos com GUILHERME SILVA RAHAL, em relação a quem houve oferecimento de acordo de não persecução penal, tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 36 (trinta e seis) pedras de crack, derivado da cocaína, 08 (oito) porções de Cannabis sativa L (maconha) e 38 (trinta e oito) eppendorfs de cocaína, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Não foi oferecido acordo de não persecução penal ao réu porque, embora tecnicamente primário, após haver sido preso em flagrante delito por idêntico crime de tráfico de drogas nestes autos, no dia 03.03.2021, sendo posto em liberdade; ele voltou a ser preso em flagrante por novo tráfico de drogas, conforme se constata por simples pesquisa no E-saj, em análise do feito nº 1518636-83.2021.8.26.0266, o que demonstra concretamente que ele se dedica à atividade criminosa, apresentando conduta criminosa habitual, o que configura causa impeditiva para o novo instituto, nos precisos termos do inciso II, do § 2º, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei nº 13.964/19, não sendo o ANPP necessário e suficiente no caso concreto para a reprovação e prevenção do crime em apuração.

A denúncia foi recebida em 31.08.2021 (págs. 107/108).

O réu foi citado (pág. 116) e apresentou resposta escrita à acusação (págs. 128/129).

Durante a instrução, foram inquiridas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado ao final (págs. 153/154).

O laudo de exame químico-toxicológico foi juntado aos autos às págs. 95/96.

Em fase de memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, condenando-o acusado nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, com base no artigo 386, inciso VII, do Código Penal e, em caso de condenação, seja a pena aplicada no mínimo legal.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 03/04), pelo boletim de ocorrência (págs. 10/12), pelo auto de exibição e apreensão (pág. 13), pelo laudo de exame químico toxicológico (págs. 94/96), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução.

A autoria também é incontestada e deve ser atribuída ao acusado.

A testemunha arrolada pela acusação, José Braz da Silva Sobrinho, Policial Civil, ouvido em Juízo, disse que recebeu uma informação de que havia uma residência que era utilizada para armazenar drogas. Relatou que diante de tal informação se dirigiu ao endereço indicado e, quando chegou, encontrou o acusado Guilherme, o qual confirmou a existência de drogas em seu quarto, sendo esclarecido que se destinava a abastecer o ponto de vendas do Rio Preto. Informou que durante a ocorrência avistaram Denis entrando no imóvel e este, ao ser indagado, admitiu que fora ao local buscar drogas para serem vendidas no ponto de tráfico do Rio Preto.

A testemunha arrolada pela defesa, Pedro Machado Valadão Neto, Policial Civil, ouvido em Juízo, disse que Denis fora abordado em frente à residência qualificada nos autos, tendo afirmado que estava indo buscar entorpecentes para abastecimento do ponto de drogas do Rio Petro. Informou que não se recorda se foi encontrado algo em posse do acusado.

Não há razão suficiente para invalidar os depoimentos dos Policiais, por suspeitos ou impedidos de depor, só porque ostentam essa qualidade, pois, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que:

"(...) nada impede que policiais ou outros servidores públicos, como quaisquer pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos destes como se, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos de seus próprios servidores. A propósito do valor probante de testemunhos policiais, oportuno trazer à colação a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal: 'VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da

repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência." (HC 73518, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293)" (TJSP, Apelação nº 0009710-21.2011.8.26.0176, 14ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. HERMANN HERSCHANDER, j. 31.03.2016).

Os testemunhos dos Policiais são suficientes para, com as demais provas carreadas aos autos, comprovarem a ocorrência do fato típico, e embasarem um decreto condenatório ao réu, vez que dotados de fé pública e idoneidade em suas alegações, mormente por terem corroborado os depoimentos na fase inquisitorial.

O réu, Denis Gonçalves Viana, interrogado em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia. Disse que estava passando pelo local dos fatos quando fora abordado pelos policiais, tendo consigo R\$ 10,00 (dez reais) e uma porção de maconha para uso próprio. Informou que os policiais disseram que seria qualificado pelo artigo 28, do Código Penal, mas quando chegou na Delegacia fora acusado pelo crime descrito na denúncia.

Embora tenha negado o delito da denúncia, sua responsabilidade penal é nítida, mormente pelas provas colhidas, em especial pela prisão em flagrante e o auto de exibição e apreensão, somados aos depoimentos dos policiais civis, tornando-se prova idônea da prática delitiva.

Necessário destacar, ainda, que o tráfico de drogas é praticado às ocultas, logo, para se prolatar decisão condenatória não há necessidade de uma sequência de provas plenas e fartas, pois tal situação não se coaduna com a realidade fática.

A decisão condenatória deve se basear em um quadro suficiente de elementos de convicção, que seja harmônico e convergente para configurar a conduta do réu, o que de fato ocorre no presente caso.

Ainda que assim não fosse, é sabido que todos os processos criminais exibem, em maior ou menor escala, algum coeficiente de incerteza, cumprindo ressaltar, porém, que é despropositado exigir, para a procedência da acusação, grau absoluto de certeza, de vez que a solução condenatória reclama, tão só, prova suficiente da autoria e da materialidade, que não se identifica com prova maciça, incontestável, reflexo sem distorções da realidade. E prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível, ou seja, juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão.

Nem se diga que a existência apenas de indícios impossibilite um decreto condenatório, pois contrariaria doutrina e jurisprudência majoritárias:

"embora não leve à certeza, a jurisprudência tem admitido a condenação quando a prova indiciária for veemente ou então quando várias pequenas circunstâncias sejam, concordes até em detalhes. Um único indício pode levar à condenação, desde que veemente. Por indício veemente entende-se aquele que, dada a sua natureza, permite razoavelmente afastar todas as hipóteses favoráveis ao acusado. (...) Às vezes uma sucessão de pequenos indícios, coerentes e concatenados, igualmente podem dar a certeza exigida para a condenação. (...) Em tal hipótese não encontramos um indício que possa ser classificado como veemente, porém a sucessão e a coerência indicam a autoria com uma dose de razoabilidade bem marcante" (Da Prova no Processo Penal - José Q. T. de Camargo Aranha).

"A prova se faz não só de maneira direta, mas também por indícios e presunções, que

devem ser analisados como todo e qualquer outro elemento de convicção, à luz do princípio do livre convencimento do Juiz. Os indícios, quando não contrariados por contra indícios, ou por prova direta, autorizam o juízo e culpa do acusado e sua condenação." (TACRIM-SP - AC - Rel. Marrey Neto - JTACRIM 7/105).

Como se vê, ficou clara a prática de tráfico ilícito de entorpecentes por parte do réu, inexistindo nos autos qualquer fato que venha ilidir sua responsabilidade penal. Imperiosa, pois, a condenação.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade e diversidade, denotam, às claras, sua predisposição: a entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil - Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. - Recurso conhecido e provido." (TJMG, ACr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Para ilustrar, aponto as lições de LUIZ FLÁVIO GOMES:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Devem-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Adel et. Al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Nesta toada, o conjunto probatório delineado nos autos é mais do que suficiente para empregar o decreto condenatório em desfavor do réu.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, e analisando a folha de antecedentes (pág. 41) observo que o réu não possui maus antecedentes, desta forma, mantenho a pena base no mínimo legal, fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a atenuante de menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, todavia, não há que se diminuir a pena aquém do mínimo legal, por força da súmula 231 do STJ, desse modo, mantenho a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira e última fase da dosimetria da pena, vislumbro estar presente a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois o réu é

primário e a acusação não conseguiu comprovar que o réu se dedicava a atividade criminosa, nem que integrasse qualquer organização, motivo pelo qual reduziu a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Sobre a redução acima aplicada, destaco que nesse sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

"O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4.º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 exige fundamentação idônea. A ausência de provas do envolvimento em atividades criminosas ou da participação em organização criminosa deve ser interpretada em benefício do acusado e, por conseguinte, não é suficiente para afastar a aplicação da causa de redução da pena. Incidência do princípio da presunção de inocência e da regra do in dubio pro reo" (HC 103225 - RN, 2.ª T., rel. Joaquim Barbosa, 11.10.2011, v.u.).

Segundo o renomado jurista e magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI, em sua obra "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol.1 -Ed. Forense - 8ª ed. - 2014 - página 348" - a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33 §4º, da Lei 11343/06:"cuida-se de norma inédita, visando a redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no artigo 33, caput, ou §1º, se primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme artigo 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda."

Vê-se, portanto, que os quatro requisitos são cumulativos, e devem estar presentes para a concessão da benesse.

Não existem dúvidas quanto aos requisitos da "primariedade", "bons antecedentes" e "integrar organização criminosa", mas estranha é a previsão a respeito de "não se dedicar às atividades criminosas". Segundo o mesmo jurista acima citado, inclusive na mesma obra, "na norma do §4º, para que se possa aplicar a diminuição de pena, afastou-se a possibilidade de ser reincidente ou ter maus antecedentes. Portanto, não se compreende o que significa a previsão de não se dedicar às atividades criminosas. Se o sujeito é reincidente ou tem maus antecedentes pode-se supor que se dedique à atividade criminosa. No mais, sendo primário, com bons antecedentes, não há cabimento em se imaginar a dedicação a tal tipo de atividade ilícita" (grifo nosso).

No caso em tela o réu é primário, impossibilitando, desta forma, a presunção de que se dedique a atividades criminosas. Pelo contrário, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a comprovação dos requisitos "dedicação às atividades criminosas" e "participação em organização criminosa" é ônus da acusação.

Desta forma, sendo o réu primário, e não logrando a acusação comprovar que efetivamente integrasse em organização criminosa, posto que o processo que a acusação menciona é posterior ao crime atual, este por si só, não forma prova suficiente para indicar que o acusado se dedicasse a prática de crimes, sendo assim, impossível a não concessão do redutor no caso em tela.

Portanto, será concedido no mínimo legal, pois a quantidade apreendida não pode ser considerada pequena, mas também nada que leve à presunção de que o réu integrava organização criminosa ou se dedicava a atividades criminosas.

Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,

por força de expressa proibição legal, e por ser a pena superior a 04 anos. Assim como, em relação à concessão do "sursis" processual.

Dito isso, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, único adequado e suficiente para reprovar sua conduta que afeta significativamente a ordem social, tendo em vista o incurso no artigo 2º, §1º da Lei nº 8.072/90, com a redação pela lei 11.464/07, os quais justificam a imposição do regime inicial mais severo.

Posto isto, CONDENO o réu DENIS GONÇALVES VIANA qualificado nos autos, ao cumprimento 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a iniciar o cumprimento no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, §4º, da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao presente processo encarcerado e deverá assim permanecer em caso de eventual recurso.

Também, após o trânsito em julgado, oficie-se a Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens eventualmente apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa.

Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais, observando-se eventual condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Arbitro os honorários do defensor nomeado, se o caso, no valor máximo da tabela vigente, expeça-se o necessário.

Em relação ao acordo de não persecução penal proposto em relação a GUILHERME SILVA RAHAL, tornem os autos conclusos para designação de audiência.

P.I.C- Arquivando-se, oportunamente.

Itanhaém, 26 de Maio de 2022.

RAFAEL VIEIRA PATARA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA